

1500097-58.2019.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500097-58.2019.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500097-58.2019.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056377/2019 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 3831909 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 743/19/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2056377 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 743/19/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Talita Cristina Campos da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

TALITA CRISTINA CAMPOS DA SILVA, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de fevereiro de 2019, por volta das 09h30min, na Rua Almirante Augusto Franceschi, nº 370, Parque Abílio Pedro, na cidade e comarca de Limeira, a acusada trazia consigo, para fins de tráfico, 07 porções de cocaína, pesando no total 2,87 g, e 01 porção de maconha, pesando 4,05 g bem como tinha em depósito, também para fins de tráfico, 30 porções de cocaína, pesando no total 13,14 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e laudo de constatação.

Segundo se apurou, na data dos fatos, a denunciada se encontrava na via pública com

drogas, para consumo de terceiros. Policiais militares, durante patrulhamento, avistaram TALITA, a qual, ao notar a aproximação da viatura, deu alguns passos para trás e se escondeu atrás do muro.

A denunciada foi abordada e negou possuir algo de ilícito, contudo ao ser informada que seria realizada a busca pessoal por policial feminina, admitiu que tinha 07 porções de cocaína na calcinha e retirou do sutiã 01 porção de maconha e a quantia de R\$34,00. Indagada sobre a existência de mais entorpecentes, ela indicou onde morava e disse que no guarda-roupa havia mais drogas.

Em diligência na residência de Talita, dentro do guarda-roupa, foram localizadas 30 porções de cocaína. A denunciada foi presa e conduzida à delegacia de polícia, onde, em revista pessoal realizada pela policial Geslaine, foram encontradas mais 07 porções de cocaína.

Oferecida a denúncia, determinou-se a notificação da acusada para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 123/124).

A denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2021 (fls. 125/126).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, com interrogatório da acusada ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 193/197) e da Defensoria Pública (fls. 201/214).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Aprecio a preliminar levantada pela defesa.

Não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar.

Como se sabe, a inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se, a bem da verdade, de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia.

A inviolabilidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. O contexto de flagrante delito e o estado de necessidade de terceiros (socorro ou desastre) prescindiriam do consentimento expresso do morador.

A configuração do flagrante delito, como se sabe, é uma das hipóteses autorizadoras do ingresso no domicílio alheio. Aqui, no conflito emergente entre a privacidade e o resguardo imediato da ordem pública, o legislador inclinou-se em favor do último.

Da hipótese daquele que é surpreendido no momento em que comete a prática delituosa ou que acaba de cometê-la (flagrante próprio), àquele que é encontrado logo depois, em poder dos objetos ou instrumentos do delito (flagrante presumido), passando pela situação de perseguição imediata e ininterrupta (flagrante impróprio), conferiu o legislador mandamento aos agentes públicos para efetivarem a prisão, independentemente de ordem judicial (art. 302 do CPP).

Ora, se a custódia em tais casos é executada diretamente, natural que o ingresso no domicílio também possa se dar diretamente até mesmo para a concretização daquela

prisão.

Então, não houve violação de domicílio, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.

Não bastasse, cabe ainda chamar a atenção que, no caso concreto, havia fundadas suspeitas da prática de crime do tráfico no local a autorizar a ação da Polícia Militar.

Revelou a prova oral que a diligência policial questionada pela defesa foi precedida de abordagem prévia da acusada na via pública. Na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando a ré tentou se esquivar da ação policial.

Feita a abordagem, houve a localização de drogas e dinheiro em seu poder. Indagada, apesar da hesitação inicial, ela confessou que mantinha mais entorpecentes no interior da sua residência.

Em razão desses fatos, houve buscas no interior da residência (entrada franqueada pela moradora) e os agentes públicos localizaram, dentro do guarda-roupa, diversas porções de cocaína.

Em resumo, a ré estava em comportamento típico de tráfico, mas foi interrompida pela ação da Polícia Militar, havendo prisão em flagrante.

Os elementos trazidos pelos policiais militares corroboraram a fundada suspeita da ocorrência de crime de tráfico no imóvel residencial ocupado pela denunciada, de crime considerado permanente, o que justificou a busca e apreensão sem mandado judicial.

Havendo, portanto, sérios e concretos indicativos da prática de tráfico no local dos fatos, não há que se falar em afronta à tese firmada em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário 603.616 do Colendo Supremo Tribunal Federal (tema 280):

“Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Não é outro o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes, a saber:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. DOMICÍLIO – VIOLAÇÃO – CRIME – FLAGRANTE. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, surge lícita a entrada forçada em domicílio sem prévia autorização judicial”. (STF, HC 177923, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 03-03-2021 PUBLIC 04-03-2021).

“Agravos regimentais em habeas corpus. Penal. Processo Penal. Crime de tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Exceção. Situação de flagrante delito. Controvérsia acerca do ingresso de policiais no domicílio (...). 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo

penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (RE nº 603.616-AgR/RG – Tema 280). 3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via processual do habeas corpus. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental não provido". (STF, HC 197268 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15-06-2021 PUBLIC 16-06-2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. (...) INVOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto a entrada na casa foi franqueada pelo ora agravante, ao passo que o referido Tema trata de entrada forçada no domicílio sem mandado judicial. 2. A instância ordinária – soberana quanto à matéria fático-probatória – entendeu que a prisão do agravante se deu em razão da situação de flagrância, e que a apreensão dos aparelhos eletrônicos foi realizada mediante autorização, tudo em conformidade com os depoimentos dos policiais militares. 3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido". (STF, ARE 1312140 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021).

"Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, com fundamento nas provas produzidas e submetidas ao contraditório, reconheceram a inexistência de entrada forçada no domicílio do recorrente, identificando a prévia justa causa para o ingresso por parte dos policiais (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STF, HC 198582 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021).

A respeito do consentimento dos moradores, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.342.077/SP (Julgamento: 02/12/2021. Publicação: 06/12/2021), reafirmou a tese fixada no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), ao assentar:

"O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. O entendimento adotado por essa Suprema Corte impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante".

Na mesma decisão, o Ministro Alexandre de Moraes anulou o venerando acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021) que exigia consentimento do morador comprovado por documento escrito da diligência policial e gravação audiovisual, eis que tais exigências consubstanciam inovação em matéria

constitucional e implantação obrigatória de medidas não previstas em lei, que são atinentes à organização administrativa e orçamentárias dos órgãos de segurança pública das unidades federativas.

Embora a defesa sustente que a versão judicial da acusada confirmaria a tese de que houve entrada forçada em domicílio, anote-se que a ré nada aludiu a esse respeito quando interrogada judicialmente (mídia).

Desse modo, deve ser dada prevalência ao depoimento dos policiais militares prestados na fase do inquisitivo e do contraditório, que se mostraram firmes e uníssonos quanto ao consentimento do morador, como adiante se verá.

A conduta da acusada, como mencionada na denúncia, de trazer consigo e manter em depósito entorpecentes para entrega a consumo de terceiros, caracteriza o delito de tráfico de drogas. É prescindível que o agente seja surpreendido praticando atos de comércio, por não ser a venda a única conduta existente no tipo penal mencionado no artigo 33 da Lei de Tóxicos.

O comércio ilícito de drogas tem na clandestinidade uma de suas principais características, o que dificulta a sua repressão. Os meios usuais de prova (testemunhal e documental) quase sempre se revelam pouco concludentes.

Logo, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso de tráfico de drogas, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, muito menos em falta de consentimento dos moradores como pretende a combativa defesa.

Não há outras preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo pericial com resultado positivo para cocaína e maconha (fls. 39/42 e 94/96), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a autoridade policial, a acusada disse que irá se manifestar somente na fase do contraditório (fls. 08).

Em juízo, a ré disse que tem 29 anos. Está desempregada atualmente. É solteira e tem uma filha pequena. As drogas eram para uso pessoal. Estava na rua. O menino parou e iria dar um tiro. A polícia apareceu. Falou que tinha drogas na sua casa, mas era para seu uso. Lá foram encontradas trinta porções de cocaína. Em seu poder tinha sete porções de cocaína e um pedaço de maconha. Tinha quinze reais em seu poder. Foi abordada perto da sua casa. Não conhecia os policiais até então. Não costumava vender drogas. Respondeu a outro processo por tráfico e foi condenada a pena de um ano e oito meses de reclusão, realmente guardava drogas naquele outro processo, aqueles fatos aconteceram posteriormente (mídia).

Sua versão não convence.

Vejamos o teor da prova oral.

A policial militar Geslaine Serrano de Oliveira disse que estava em atividade e foi solicitada para fazer revista pessoal na delegacia. Foi com a ré ao banheiro. Ao tirar as roupas, nas partes íntimas, caíram sete papelotes de cocaína. Entregou o que encontrou ao sargento que conduzia o caso. Não encontrou maconha em seu poder.

A acusada nada disse a ela sobre o ocorrido (mídia).

O policial militar Rafael Siqueira contou que o caso ocorreu em 2019. Era motorista da viatura. No local indicado na denúncia, abordaram a ré. Indagada, ela disse não ter nada em seu poder. Falaram que iriam chamar uma policial feminina para fazer uma busca pessoal. Foi aí que ela disse ter dinheiro e drogas. Não se recorda a quantidade encontrada. A genitora franqueou a entrada na residência e encontraram mais drogas no quarto da ré. Não se recorda o que ela falou. Estava na função de motorista, quem fez a busca foi seu colega Marcelo. Não a conhecia (mídia).

O policial militar Marcelo Francisco da Silva disse inicialmente que não se recorda dos fatos. O crime ocorreu em 2019. A revista foi realizada pela policial Geslaine na delegacia e lá foram encontradas mais drogas, não sabe a quantidade exata. Sabe que a acusada foi abordada na rua em questão, estava com o policial Siqueira no dia dos fatos. Não lembra a quantidade encontrada. Olhando a ré, conseguiu lembrar um pouco dos fatos. Havia drogas no guarda-roupa, mas não sabe o tipo e nem a quantidade. Confirma a abordagem na rua. Uma busca pessoal seria realizada no distrito policial. Não conhecia a acusada até então (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, “a priori”, valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais “lato sensu”. Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pelo teor da prova oral colhida, policiais militares faziam patrulhamento de rotina quando avistaram a acusada, a qual ficou assustada com a presença dos guardas.

Na abordagem, a acusada negou possuir algo ilícito, mas ao tomar conhecimento que iria ocorrer revista pessoal por policial feminina, a ré admitiu que tinha drogas e dinheiro em seu poder.

Em diligências pela residência da acusada, mais precisamente dentro de seu guarda roupa, foram localizadas 30 porções de cocaína. A ré foi presa em flagrante delito.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico, haja vista a quantidade, natureza, diversidade e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína e maconha), a conduta da acusada quando da prisão, as circunstâncias e o local da abordagem, tudo a apontar a ré como pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 – Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas – Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Ausência de visualização de atos de mercancia – Irrelevância – Tipo misto ou de conteúdo variado – Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como das circunstâncias da prisão em flagrante, existindo depoimento incriminador de policiais militares.

Na esteira dos ensinamentos de Cleber Masson:

"Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica,

necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias "mulas" (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

Não é diferente o posicionamento jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecentes - Dolo de traficar - Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) - Descabimento Provido o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...)" (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indubitáveis. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância.(...)" (TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

A combativa defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos policiais militares para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Por outro lado, não foram arroladas testemunhas de defesa que corroborassem a versão da acusada de não ter qualquer envolvimento com a traficância ilícita, devendo prevalecer o relato dos policiais militares que faziam patrulhamento de rotina e a prenderam em flagrante delito.

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu

momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra a acusada, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são inteiramente favoráveis a ré, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula n. 231 do Colendo STJ.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

Sendo a ré primária, de bons antecedentes e não havendo prova de que integra organização criminosa, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4ª, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a reprimenda em 2/3 (dois terço), tornando-se definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada.

A esse respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário:

"Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda" (GRECO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2008).

O valor do dia multa será fixado no mínimo legal.

Considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no acórdão proferido no HC 118.553/MS, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para admitir a fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal.

O tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES.

Dessa forma, fixo o regime inicial aberto para o caso em questão.

Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme Súmulas 440/STJ e 718 e 719 do Colendo STF, que assim dispõem:

Súmula 440/STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Súmula 718/STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula 719/STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, aplica-se a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na fixação do regime prisional, assim como as decisões dos Tribunais Superiores (STF e STJ).
Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, a partir do julgamento do HC 97.256/RS pelo STF, declarando incidentalmente a parcial inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei nº 11.343/2006, o benefício da substituição da pena passou a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal.

Não basta a primariedade para fazer jus à substituição, pois deve o juiz levar em conta, além da natureza e da quantidade da substância ou do produto, a personalidade do agente e a conduta social do agente.

Nesses termos, entendo que o comportamento da acusada, desde a polícia, bem como em juízo, leva a crer que sua personalidade, no que tange à maturidade e a responsabilidade, torna inviável a conversão da pena em restritivas de direitos.

A medida alternativa não é suficiente em razão da falta de atendimento do pressuposto subjetivo previsto no artigo 44, inciso III, do CP (cf. STJ, HC 435.632/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018; HC 390.554/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar TALITA CRISTINA CAMPOS DA SILVA, qualificada nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no seu menor valor, como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c a redução prevista no §4º do art. 33 da mesma lei.
Como respondeu solta, poderá recorrer desta em liberdade.
A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária da ré e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida, com as cautelas de praxe pela qual representou a autoridade policial.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido.

Após o trânsito em julgado, o nome da acusada deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA